刑法第十三講筆記

間接正犯的類型（承接第十二講）

一、錯誤支配（欺騙）類型

1. 欺騙他人從事不該當構成要件的自損行為

- 例：騙盲人去摸高壓電 → 成立**間接正犯**（有意思支配）
- 對比：教唆自殺 → **非間接正犯**（被害人仍有自主決定空間）→ 需透過獨立犯罪類型（如加工自殺罪 §275）處理

2. 利用他人無故意、無過失的行為

- 經典案例：在飲料中下毒，不知情的人端給被害人飲用
- 工具人完全不知情 → 幕後者成立間接正犯

3. 利用他人成立過失犯的行為

- 例：掉包點滴為福馬林，護理師未發現而施打
- 護理師僅成立過失犯，幕後者為間接正犯

4. 利用他人欠缺法定意圖的行為

- 例：騙路人「幫我把腳踏車牽來」，路人無不法所有意圖
- 路人不成立竊盜罪（欠缺主觀意圖），幕後者為間接正犯

5. 利用他人阻卻違法的行為

- 例：持假拆除命令使拆除大隊依法執行
- 工具人行為阻卻違法（依法令行為），幕後者為間接正犯

6. 利用他人容許構成要件錯誤

- 例（ABC踏青案）：A 向 C 喊抓小偷，C 信以為真而撲倒 B → C 有容許構成要件錯誤
- 考題（高考法制）：丙喊「抓小偷」→ 警察丁撲倒乙 → 丙成立間接正犯（第5種或第6種皆有可能）

7. 利用他人不可避免的禁止錯誤（法律面錯誤）

- 例：漢人利用原住民獵捕保育動物
- 原住民因文化背景產生不可避免的禁止錯誤 → 幕後者為間接正犯

二、利用無責任能力人

類型	結論
§19 精神障礙者	一定論間接正犯（無疑問）
未滿14歲者	多數說 vs 少數說（見下）

利用未滿14歲者的爭議：

- **多數說（實質認定）**：視工具人實際辨識能力
    - 幼童 → 間接正犯
    - 12-13歲（已有一定認知能力）→ 教唆犯
- **少數說（許澤天）**：一律論間接正犯
    - 理由：立法者設定14歲為形式界限，不應因學說解釋而鬆動
    - 主張「§19 用形式標準，§18 也應一致」

三、強制支配（威脅）類型

1. 強制他人從事刑事不法行為

- **判斷關鍵**：被強制的工具人能否主張**緊急避難**
    - 能主張緊急避難（= 別無選擇）→ 幕後者為**間接正犯**

        - 例：威脅殺全家 → 工具人別無選擇
    - 不能主張緊急避難（= 尚有選擇空間）→ 幕後者僅為**教唆犯**
        - 例：威脅流出裸照 → 法益權衡不成立緊急避難

2. 強制他人從事不該當構成要件的自損行為

- 例：逼迫盲人去摸高壓電
- 工具人行為不該當構成要件（自傷非犯罪）→ 幕後者為間接正犯

3. 單純把他人作為物質工具

- 例：踹胖子倒在瓷器攤上
- 此時論**直接正犯**（非間接正犯），因無意思支配，工具人完全被當作物體

正犯後的正犯

> **定義**：工具人本身已成立故意犯罪，但幕後者仍因更高的支配地位而成立間接正犯。

類型一：利用他人對具體行為意義的錯誤

- = 利用有**輕罪故意**的他人
- 例：甲騙乙說加的是瀉藥，實為氰化物 → 乙有傷害故意（輕罪），甲成立殺人罪的**正犯後正犯**

利用他人單純動機錯誤 → 非間接正犯

- 例：甲騙乙說「丙在跟你老婆搞曖昧」，乙一怒殺丙
- 乙有充分自主決定能力，僅動機被操弄 → 甲只能論**教唆犯**（非間接正犯）
- 理由：工具人的自主決定空間完整，無免責可能

類型二：利用他人等價客體錯誤（借刀殺人）

- 例：甲想殺丙，騙乙說「丙今晚會穿紅衣」，實際穿紅衣者是丁 → 乙殺了丁
- 許澤天見解：此已超越單純動機錯誤，工具人如**盲目執行者** → 成立間接正犯
- 此與單純動機錯誤的區別：工具人對攻**擊對象**認知錯誤，而非僅動機受騙

類型三：利用他人可避免的禁止錯誤

- 工具人有可避免的禁止錯誤（§16 減輕）→ 幕後者仍有支配地位 → 可論正犯後正犯

組織支配

要件

要件	說明
①**權力機構組織**	須為具有層級結構的組織
②**執行者可替換性**	個別執行者可被替換，組織不因人而停
③**法益脫落性**	組織活動脫離正常法秩序

適用範圍

- **典型適用**：犯罪組織、極權國家軍事機構
    - 例：江南案（情報局長下令暗殺）
- **企業組織可否適用？**
    - **肯定說**：員工如螺絲釘，具可替換性
    - **否定說**：企業組織之控制程度與犯罪組織差距過大，頂多論教唆犯

不能成立間接正犯的類型

類型	說明	可否論共犯？

己手犯	只有親自實行才能成立的犯罪（如偽證罪）	不能論間接正犯或共同正犯，但**可論教唆犯、幫助犯**
純正身分犯	學理上認為無身分者可透過間接正犯實現（例外），但**實務未承認**	留待 §31 討論
過失犯	幕後者（甲）不能是過失的；工具人（乙）可以是過失的	—

間接正犯的著手與未遂

> **近年考試高頻考點**

三說比較

學說	著手時點	代表學者
被利用人行為開始說（整體理論）	工具人開始實行時才算著手	—
利用人行為開始說（個別理論）	利用人完成其行為時即著手	—
回歸一般著手理論	以主客觀混合理論判斷 → 結論近似第二說	林鈺雄、林山田

常見考題

- **平埔酒灑案**：利用人設好毒酒 → 何時著手？
- **演員搶奪案**：利用演員做不知情的工具 → 何時著手？
- **咖啡端到一半灑掉案**：工具人中途失手 → 是否已著手？

間接正犯的錯誤

間接正犯與教唆犯的關係：包含關係（非互斥）

- 教唆犯要件：A、B、C、D
- 間接正犯要件：A、B、C、D + **E（意思支配）**
    - E = **主觀支配意思 + 客觀支配事實**
- 踰越行為：工具人多做 → 幕後者只就原本教唆範圍負責

四種利用行為錯誤

情形	主觀認知	客觀事實	E 要件	結論
① 誤以為工具人**有**責任能力（實無）	無支配意思	有支配事實	E 不充足	**教唆犯**
② 誤以為工具人**無**責任能力（實有）	有支配意思	無支配事實	E 不充足	**教唆犯**
③ 誤以為工具人**有**故意（實無）	本欲教唆	工具人僅過失	無法從屬	**過失致死正犯**
④ 誤以為工具人**無**故意（實有）	有支配意思	無支配事實	E 不充足	傳統/林鈺雄：**教唆犯**；德國說：間接正犯未遂；許恆達：過失正犯

- 被利用人發生客體錯誤或打擊錯誤 → 留待教唆犯章節一併討論

共同正犯

定義

> 二人以上基於犯意聯絡，共同分擔犯罪行為的實行。

交互歸責原則

- **一人著手，全體著手；一人既遂，全體既遂**
- 不問個別行為人的因果關係與結果歸責
- 構成**罪疑惟輕的例外**（不能主張「不是我做的」）
- **科刑各論各的**：交互歸責止於「犯罪成立」，不及「科刑」

著手爭議

學說	內容
多數說	一人著手，全體著手
少數說（黃惠婷）	個別認定各行為人是否著手

共同正犯三大要件

要件一：二人以上

學說	內容
傳統說	限於有責任能力者
學說新見	不限於有責任能力者，事實上有意思能力即可

要件二：犯意聯絡

- 放在客觀或主觀要件皆可（老師傾向客觀）
- **明示 / 默示**皆可，但**單純沉默不算**犯意聯絡
- 可以是**直接**或**間接**犯意聯絡
    - 間接犯意聯絡：如詐騙集團成員互不認識，但透過首腦連結
- **同時犯（平行正犯）**：偶然同時犯罪，無犯意聯絡 → 非共同正犯

不同故意形態可否成立共同正犯？

- **實務肯定**：直接故意 + 間接故意 → 可成立共同正犯（本質上皆為故意）
- 「故」買贓物罪之「故」→ 非限於直接故意，僅為湊字數

要件三：行為分擔

- **不要求**每個人都做完整的構成要件行為
- 三種行為分擔型態：

型態	說明
全體都做構成要件行為	甲乙各刺被害人一刀
有人做構成要件行為＋有人做構成要件以外行為	甲架住被害人，乙持刀刺
每人都只做部分構成要件行為	搶銀行：甲開車接應、乙持槍威嚇、丙跳入櫃檯取財

相續共同正犯（共同正犯最難的問題）

時間軸



階段	說明	存在於何種犯罪
著手 → 既遂	藍色段	一般犯罪
既遂 → 形式終了	橘色段	**繼續犯**（如私行拘禁）、**接續犯**、**集合犯**（如偽造貨幣）
既遂 → 實質終了	黃色段	主要存在於**取得型財產犯罪**（如竊盜後持有穩固前）
實質終了之後	紅色段	不可能相續，只能論後行犯（如贓物罪、湮滅證據罪）

- **著手前加入** → 一般共同正犯（無爭議）
- **實質終了後加入** → 不可能成立共同正犯

藍色段（著手後、既遂前加入）

- 一般情形較無爭議，但涉及**雙行為犯**（如強盜罪）時有爭議

強盜罪考題（462考題）：

- 甲持刀強制 + 乙僅負責取財 → 乙在著手後既遂前加入
- 強盜 = 強制 + 竊盜 → 乙只做了竊盜，未做強制

個人責任原則：每個人只為自己實際做過的行為負責

學說	結論	理由
否定說	乙不成立強盜罪共同正犯	乙只做竊盜未做強制，可論①**竊盜罪共同正犯** 或 ②**強盜罪相續幫助犯**（許澤天：幫助犯不法內涵較低，對構成要件要求可放寬）
肯定說（傳統/實務/陳子平）	乙成立強盜罪共同正犯	乙的取財是在**利用甲先前造成的強制狀態**，前行為效果仍持續中，後行為人利用該持續效果，應為整體結果負責

橘色段（既遂後、形式終了前加入）

- **較無爭議**，可成立相續共同正犯
- 理由：後加入者**本身也在實現構成要件行為**
- 例一：私行拘禁（繼續犯）→ 鄰居來幫忙看守被拘禁者 → 鄰居成立 §302 共同正犯
- 例二：偽造貨幣（集合犯）→ 鄰居加入製造行列 → 成立 §195 共同正犯

黃色段（既遂後、實質終了前加入）— 最有爭議

案例（許澤天）：

- 甲搶得皮包，乙緊追不捨
- 甲以手機聯絡丙出來接應
- 甲在指定地點把皮包拋給丙，甲最終擺脫乙，向丙取回皮包並分贓

> 丙在甲**既遂後**才加入（黃色段），丙可否成立強盜罪共同正犯？

學說	結論	理由
肯定說（實務）	可以	丙的加入**加深被害人法益侵害**（沒有丙的話被害人可能奪回皮夾）
否定說	不可以	甲拿著贓物逃跑的行為**本身並未實現任何構成要件**，丙在共同什麼？

實務立場：對相續共同正犯幾乎**全面肯定**，除紅色段外皆承認（只要有**相互利用補充關係**即可）

過失的共同正犯

瑞士滾石案

- 甲乙在山坡上推石頭，路人被石頭砸死，但無法確定是甲還是乙推的石頭

學說爭議

學說	結論	理由
傳統否定說	過失犯不能成立共同正犯	共同正犯以犯意聯絡為必要，過失行為人之間不可能有犯意聯絡
肯定說（越來越多學者）	過失犯可以成立共同正犯	① 法條（§28）僅規定「二人以上共同」，未限定故意或過失；② 承認有實益：可適用**交互歸責**（罪疑惟輕的例外），避免雙方都以「不是我的石頭」脫罪

> 傳統否定說被批評為「只回答問題的表面」（犯意聯絡不能換成其他要件嗎？），未觸及問題本質。

陰謀與預備的共同正犯

- §28 規定「共同**實行**犯罪之行為者」
- **實行 = 著手**（著手才有實行）
- 修法前寫「實施」→ 可涵蓋陰謀預備的共同正犯
- 修法後改為「實行」→ **排除陰謀、預備階段的共同正犯**
- 結論：至少全體中有一人著手，才能成立共同正犯

共謀共同正犯

定義

- 有提供犯意聯絡（甚至是犯罪集團核心人物），但**行為當下沒有出現**
- = 有犯意聯絡，**欠缺行為分擔**

案例

> 甲乙丙丁相約搶銀行。甲負責計畫安排人力，乙開車接應，丙丁去銀行行搶。行搶當天**甲在家中睡覺**。甲是否為共同正犯？

釋字第 109 號

- 「以自己共同犯罪意思，參與**實施構成要件以外的行為**」→ 此指開車接應者（非共謀者）
- **(實務立場：無條件肯定共謀共同正犯)**

學說見解

學說	立場	內容
嚴格的犯罪支配論	**否定**共謀共同正犯	不在場者不可能對現場犯罪有支配，頂多論教唆犯。**例外**：行為當下以通訊方式即時瞭解現場狀況 → 可論共同正犯
溫和的犯罪支配論	**有條件承認**	若共謀者為整個集團核心首腦人物（**共同行作犯罪計畫**或**組織犯行**），即使行為當下未到場，仍為共同正犯
實務	**無條件承認**	只要有犯意聯絡即可

比較案例 — 小弟「阿悟」：

- 阿悟剛加入集團，每次行前會議都有參與，但未提出建設性意見
- 其他人搶劫時，阿悟也在家中睡覺，僅協議參與分贓
- 照**實務** → 共同正犯 ✔
- 照**溫和犯罪支配論** → 未達核心首腦程度 → **非共同正犯** ✘

> 對行為人**最有利**的學說 = 嚴格的犯罪支配論

擇一共同正犯

定義

- 共同正犯中，各行為人提供的分擔方案，事後只有一個會有作用，另一個被判定無效
- 例：甲乙約定殺 A，A 的豪宅有前門後門 → 甲守前門，乙守後門 → A 從後門離家，被乙殺死 → 甲的埋伏完全無用

學說爭議

學說	結論	理由
假說實務見解	肯定擇一共同正犯	實務連共謀共同正犯（完全無行為分擔）都無條件肯定，擇一者至少有到場，僅事後判定無效，**舉重以明輕**，當然更應肯定
許恆達（乙說）	**否定**擇一共同正犯	行為分擔應從**事後角度**認定，事後無實質貢獻 → 不算行為分擔。但否定後，被判定無用者仍可論**精神幫助犯**（守前門使守後門者更安心）
德國多數說	**肯定**擇一共同正犯	行為分擔不需事後真的有效，只要**事前可預期有貢獻**即可。包括非典型貢獻

> 許澤天老師採否定說（少數說）。

考題解析

警特四等第 19 題

- 甲乙沒有事前溝通，一前一後包夾被害人，拳打腳踢致死
- **犯意聯絡**：默示的犯意聯絡（動作眼神有默契）
- **罪名**：
    - §302 私行拘禁剝奪行動自由共同正犯
    - §271 殺人既遂共同正犯
- **競合**：為殺人而壓制被害人 → 剝奪行動自由部分被殺人罪**吸收**，不另論
- **最終結論**：甲乙論**殺人既遂之共同正犯**
- 注意：非傷害致死的共同正犯（加重結果犯的共同正犯是更進階的考點，警特四等通常不會考到此程度）